

臺灣高等法院刑事判決

115年度上訴字第462號

上訴人 陸孝順
即 被 告

0000000000000000

(另案於法務部○○○○○○○○執行)

選任辯護人 陳宏銘法扶律師

上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣臺北地方法院114年度訴字第701號，中華民國114年11月12日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第32711號、112年度偵字第22382號）提起上訴，判決如下：

主 文

上訴駁回。

犯罪事實及理由

一、本院審理結果，認原審以被告犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑5年4月；扣案行動電話1具（含0000000000號SIM卡）沒收；未扣案犯罪所得新臺幣（下同）2千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，應予維持，引用附件原判決記載之犯罪事實、證據及理由。

二、上訴人即被告陸孝順辯解略以：只是幫忙向邱銘祥收取2千元，並交付甲基安非他命給邱銘祥，應該只成立幫助販賣毒品罪；自白犯行並供出毒品上游，應適用毒品危害防制條例第17條第1項、第2項規定減輕刑度。

三、本院之論斷：

（一）被告供述毒品取自曾英富的事實，已經臺灣新北地方檢察署檢察官偵查，認曾英富犯罪嫌疑不足而不起訴處分，並經再議駁回確定。足認並無因被告之供述而查獲販毒來源的事實，不符合毒品危害防制條例第17條第1項之減刑要件，已經原判決第5至6頁詳細論駁，並且辯護人也陳述目前確實沒有查獲毒品上游的結果（本院卷第127頁第26行）。被告上訴仍然辯稱應依毒品危害防制條例第17條第1項規定減刑，

01 不足採信。

02 (二)毒品危害防制條例第17條第2項規定：「犯第4條至第8條之
03 罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」所謂「自
04 白」意旨自白內容應具有基本犯罪構成要件，包括販毒的毒
05 品金額、種類、交易時間、地點及營利意圖。若未充足上述
06 要件，自無從認其已就販毒之事實自白，即不適用該減輕其
07 刑規定（最高法院114年度台上字第6593號判決參照）。被
08 告於警詢、偵查均供稱只是協助邱銘祥向曾英富購買毒品，
09 並未因此獲利；於本院並且辯稱僅成立幫助販毒罪，明確否
10 認所為構成販賣第二級毒品罪（本院卷第121頁）。被告否
11 認販賣毒品的事實及營利意圖，既未於偵查、審理中自白犯
12 罪，自無毒品危害防制條例第17條第2項減刑規定之適用。

13 (三)凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論是否參與犯罪構成要
14 件行為，皆為正犯；以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，若
15 參與犯罪構成要件行為，同屬正犯；必以幫助他人犯罪之意
16 思而參與犯罪構成要件以外的行為才構成幫助犯（最高法院
17 114年度台上字第6590號判決參照）。被告親自向邱銘祥收
18 取2千元並交付第二級毒品甲基安非他命給邱銘祥，是實行
19 毒品交易行為之人，親自參與販賣毒品構成要件行為，自屬
20 販毒罪之正犯而非幫助犯。

21 (四)被告之法院前案紀錄表共45頁，有許多施用毒品犯行紀錄，
22 更由施用毒品進而販賣毒品，惡性加重且構成累犯，警詢、
23 偵查均否認販毒，而原審引用刑法第59條「酌量減輕其刑」
24 之規定，量處有期徒刑5年4月，幾乎減除法定最低刑有期徒
25 刑10年之一半，已然極度從輕量刑，而非「酌量減輕其
26 刑」。雖然檢察官主張不應以刑法第59條減刑；然檢察官並
27 未對被告刑之不利益上訴，受限於刑事訴訟法第370條第1項
28 前段規定，難認原審對於屬於法院裁量職權之刑法第59條的
29 適用有所不當，只能維持原判決刑度。

30 (五)販毒罪是世界公罪。原判決第7至8頁已詳述量刑審酌理由。
31 被告於警詢、偵查皆否認犯行，雖於原審坦白認罪，然於本

01 院又辯稱只是幫助販毒，犯後態度不佳。被告之犯行並非最
02 輕微，觸犯法定刑10年以上有期徒刑重罪，已經原審以刑法
03 59條規定大幅度寬減其刑，量處有期徒刑5年4月，被告上訴
04 指稱原判決量刑過重，並就原審已經論駁審認之事實重覆爭
05 辯，並無新事證，無可推翻原判決。上訴無理由，應予駁
06 回。

07 據上論斷，依刑事訴訟法第368條，判決如主文。

08 本案經檢察官沈念祖到庭執行職務。

09 中 華 民 國 115 年 2 月 26 日
10 刑事第二十三庭審判長法官 許永煌
11 法官 程欣儀
12 法官 郭豫珍

13 以上正本證明與原本無異。

14 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
15 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
16 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

17 書記官 蘇 婷

18 中 華 民 國 115 年 2 月 26 日

19 附錄：本案論罪科刑法條全文

20 毒品危害防制條例第4條第2項

21 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒
22 刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。

23 附件：原判決

24 臺灣臺北地方法院刑事判決

25 114年度訴字第701號

26 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

27 被 告 陸孝順 男（民國00年0月00日生）

28 身分證統一編號：Z000000000號

29 住○○市○○區○○街00號4樓

30 （現另案於法務部矯正署臺北監獄執行）

31 選任辯護人 本院公設辯護人張紋綺

上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第32711號，112年度偵字第22382號），本院判決如下：

主 文

陸孝順販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年肆月。
扣案之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事 實

一、陸孝順明知甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款列管之第二級毒品，不得販賣，適邱銘祥於民國111年6月14日亟欲施用甲基安非他命，故於該日上午9時36分許請友人呂理傑（其所涉幫助施用第二級毒品罪嫌，經本院另行審結）協助其取得甲基安非他命，呂理傑即於該日上午9時41分許後不久，以LINE通訊軟體與陸孝順聯繫購買甲基安非他命事宜，陸孝順接獲上開購毒訊息後，竟意圖營利，基於販賣第二級毒品之犯意，透過呂理傑將交易毒品之數量、價格及地點轉告邱銘祥，待邱銘祥依約於該日上午9時50分許抵達陸孝順位於新北市○○區○○街00號4樓住處樓下後，邱銘祥即請呂理傑通知陸孝順，陸孝順旋即下樓將甲基安非他命1克交與邱銘祥，並當場向其收取新臺幣（下同）2,000元之價金。

二、案經新北市政府警察局新店分局報告臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）檢察官偵查後起訴。

理 由

壹、程序事項：

本案所引用之供述及非供述證據，經本院依法踐行調查證據程序，檢察官、被告陸孝順及辯護人均同意各該證據之證據能力（見本院訴字卷第179頁），復查無依法應排除其證據能力之情形，是後述所引用證據之證據能力均無疑義。

貳、實體事項：

01 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

02 (一)上開犯罪事實，業據被告於本院審理中供陳不諱（本院訴字
03 卷第178至181、265頁），且經證人呂理傑於警詢及偵查中
04 （見偵字第22382號卷第33至45、61至66頁，偵字第32711號
05 卷第265至269頁）、證人邱銘祥於偵查中（見偵字第32711
06 號卷第301至303頁）證述明確，並有對話紀錄截圖（見偵字
07 第22382號卷第83至86頁）、監視器錄影畫面翻拍照片及刑
08 案照片（見偵字第22382號卷第93至97頁上方照片）、行動
09 電話聯繫資訊翻拍照片（見偵字第22382號卷第108頁）、搜
10 索現場照片（見偵字第22382號卷第109至123頁）存卷可
11 參，復有VIVO廠牌行動電話1具（含門號0000000000號SIM卡
12 1枚）扣案可證，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪
13 以採信。

14 (二)衡諸我國查緝販賣毒品之執法甚嚴，且販賣毒品係違法行
15 為，非可公然為之，亦無公定價格，容易分裝並增減份量，
16 而每次買賣之價量，可能隨時依雙方關係深淺、資力、需求
17 量及對行情之認知、來源是否充裕、購買者被查獲時供述購
18 買對象之可能風險之評估等情形，而異其標準，非可一概而
19 論，販賣之人從價差或量差中牟利之方式雖異，其意圖營利
20 之販賣行為則同一，是倘非有利可圖，一般人當無甘冒重度
21 刑責而提供毒品給他人之可能。況被告於本院準備程序中自
22 陳：我把毒品賣給邱銘祥是賺量差，我有拿一點起來施用等
23 語（見本院訴字卷第181頁）。顯見被告係具販賣第二級毒
24 品以牟利之意圖甚明。

25 (三)綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論罪
26 科刑。

27 二、論罪科刑：

28 (一)按甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列
29 管之第二級毒品，依法不得販賣。是核被告所為，係犯毒品
30 危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。

31 (二)被告於販賣毒品前意圖販賣而持有第二級毒品之低度行為，

01 應為販賣之高度行為所吸收，不另論罪。

02 (三)刑之加重事由：

03 被告前因 1.違反毒品危害防制條例案件，經本院以99年度訴
04 字第1330號判決判處有期徒刑5月確定； 2.違反毒品危害防
05 制條例案件，經本院以99年度訴字第1989號判決判處有期徒
06 刑1年、9月，應執行有期徒刑1年7月確定； 3.違反毒品危害
07 防制條例案件，經本院以99年度訴字第1936號判決判處有期
08 徒刑10月確定； 4.違反毒品危害防制條例案件，經本院以10
09 0年度訴字第455號判決判處有期徒刑1年2月、9月，應執行
10 有期徒刑1年8月確定； 5.違反毒品危害防制條例案件，經本
11 院以100年度訴字第653號判決判處有期徒刑1年2月、10月，
12 應執行有期徒刑1年8月確定； 6.違反毒品危害防制條例案
13 件，經本院以100年度訴字第1054號判決判處有期徒刑1年2
14 月確定，上開罪刑經本院以100年度聲字第3412號裁定定應
15 執行有期徒刑4年，被告入監執行後，於105年9月6日縮短刑
16 期假釋出監，惟假釋經撤銷而應執行殘刑有期徒刑1年7月5
17 日； 7.違反毒品危害防制條例案件，經本院以106年度審簡
18 字第1074號判決判處有期徒刑3月確定； 8.違反毒品危害防
19 制條例案件，經本院以106年度審簡字第2012號判決判處有
20 期徒刑5月確定； 9.違反毒品危害防制條例案件，經本院以1
21 07年度審簡字第1925號判決判處有期徒刑6月確定，上開 7.
22 至 9.所罪刑經本院以108年度聲字第1161號裁定定應執行有
23 期徒刑11月確定； 10.違反毒品危害防制條例案件，經本院以
24 107年度審簡字第2617號判決判處有期徒刑6月確定，上開罪
25 刑接續執行，於110年6月24日縮刑期滿執行完畢出監，此有
26 臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參，是其於受有期徒刑
27 執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為
28 累犯，惟本院審酌被告前案所為，均屬施用毒品犯行，與其
29 於本案所犯之販賣第二級毒品罪，不僅罪質相異，其犯罪情
30 節、所侵害之法益種類均有所不同，難認被告對於刑罰之反
31 應力薄弱並具相當之惡性，而有再延長其受矯正教化期間之

必要，依司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，不予加重其最低本刑。

(四)刑之減輕事由：

- 1.按毒品危害防制條例第17條第2項規定「犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，係為鼓勵是類犯罪行為人自白、悔過，並期訴訟經濟、節約司法資源而設，故須於偵查及審判中皆行自白，始有適用。此所謂「自白」，係指對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意。由於自白著重在過去犯罪事實之再現，凡就犯罪構成要件事實之全部或主要部分為肯定供述者，即屬自白，至被告就犯罪構成要件事實為自白後，對於此等構成要件事實應成立何罪等為不同之法律上評價，或主張另有阻卻違法、阻卻責任事由者，既非爭執犯罪構成要件事實之存在，尚不能依此即認被告並無自白，而謂無上述減刑規定之適用。以販賣毒品而言，其與轉讓、合資、代購、幫助施用等行為，客觀上均有將毒品交付予他人之外觀，所不同者，厥為行為人「營利意圖之有無」，而為販賣毒品之主觀構成要件，被告若否認其所為販賣毒品犯行之營利意圖，或就營利意圖相關之重要構成要件事實有所爭執，即難認被告有就所為犯罪自白，自無從邀前開減刑寬典，此與被告坦承其營利意圖或自白相關重要構成要件事實（如坦認有獲得價差、量差或其他利益），但就應成立何罪有所爭執之情形，顯屬有間（最高法院113年度台上字第4948號判決意旨參照）。被告之辯護人固為其利益，請求本院就被告所犯上揭之罪，依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。惟查，被告於警詢及偵查中均供稱係協助邱銘祥向曾英富購買毒品，其並未因此獲利，更明確否認其所為構成販賣第二級毒品要件（見偵字第22382號卷第17至18頁，偵字第32711號卷第189至190、368頁），揆諸上開說明，既然被告於偵查中從未坦認有營利意圖，應認被告並無在偵查中自白犯罪，自無上開減刑規定之適用，附此敘明。

01 2.次按毒品危害防制條例第17條第1項規定：「犯第4條至第8
02 條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正
03 犯或共犯者，減輕或免除其刑。」乃為獎勵毒品案件被告積
04 極協助犯罪偵查機關追查毒品來源、防止毒品擴散之減刑規
05 定。本項之適用，客觀上應具備：(一)關聯性：被告所供述之
06 他人毒品犯罪，需為被告本案犯行之「毒品來源」，彼此具
07 備密接關聯性，若被告雖供出其自他人處取得毒品，然因時
08 間先後順序等因素，無從認係本案犯行所用之毒品者，核僅
09 屬對於他人涉犯本案無關之其他毒品犯罪所為告發，要非就
10 其所涉案件之毒品供出來源，既無助本案之追查，即不具
11 「關聯性」；(二)實質幫助性：被告供述他人之毒品犯罪，需
12 經偵查犯罪之公務員發動偵查並因而查獲，始具備實質幫助
13 性，所謂「查獲」，固不以所供之毒品來源業經檢察官起訴
14 或法院判刑為必要，但仍應有相當之證據足資證明被告指述
15 他人犯罪之真實性、完整性與可信性，而達於起訴門檻之證
16 據高度，例如該毒品來源亦坦認其為被告所涉案件之毒品供
17 給者，或有其他證據足以補強被告對該毒品上手之指述，使
18 其指述之事實達於高度蓋然性者，方屬相當；此外，被告主
19 觀上亦需具備(三)協力意願：即被告需具有協助犯罪偵查機關
20 查獲毒品來源之主觀意思，而為其毒品來源有關之供述或提
21 出證據，始足當之（最高法院113年度台上字第283號判決、
22 114年度台上字第3032號判決、114年度台上字第1158號判決
23 意旨參照）。經查，被告固曾於偵查中提供其販賣毒品來源
24 「曾英富」之相關資訊予檢、警（偵字第22382號卷第17至1
25 8頁，偵字第32711號卷第188至191、367至368頁），且新北
26 市政府警察局新店分局亦回函表示該分局因被告供出毒品來
27 源而查獲曾英富，業於111年10月20日以新北警店刑字第111
28 4155544號刑事案件報告書移請新北地方檢察署（下稱新北
29 地檢署）偵辦，此有該分局114年8月29日新北警店刑字第11
30 44127573號函（見本院訴字卷第207頁）存卷可參，然根據
31 該函所附上開刑事案件報告書所載（見本院訴字卷第211至2

15頁），被告供出關於曾英富販賣第二級毒品予其之時間，係於111年9、10月間，均在本件被告被訴販賣第二級毒品予邱銘祥之時間（111年6月14日）之後，已實難認被告供出曾英富販賣毒品犯行與被告本案犯行有何時序關聯性，又新北地檢署檢察官偵查後，認曾英富犯罪嫌疑不足，而以111年度偵字第53090號為不起訴處分，經檢察官職權提起再議後，復經臺灣高等檢察署檢察長以112年度上職議字第2698號為駁回再議之處分確定，此亦有該不起訴處分書及駁回再議處分書（見本院訴字卷第217至221頁）存卷可考，該不起訴處分書明確記載被告雖曾於警詢中供稱曾英富販售第二級毒品予其，然於該案偵查中卻翻異其詞，否認曾英富曾販售毒品予其，而被告所提供其與曾英富間之LINE通訊軟體對話紀錄亦未顯示交易毒品之訊息，由此可見被告主觀上並不具有查獲毒品來源之協力意願，客觀上亦未有實質幫助性，揆諸上揭說明，本件無從認定業因被告之供述而查獲其等本案販賣毒品之來源，無從依毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕其刑，附此敘明。

3.刑之量定，為求個案裁判之妥當性，法律固賦予法院裁量權，但此項裁量權之行使，除應依刑法第57條規定，審酌行為人及其行為等一切情狀，為整體之評價，並應顧及比例原則與平等原則，使罪刑均衡，輕重得宜，以契合社會之法律感情。刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等等），以為判斷（最高法院95年度台上字第6157號判決意旨參照）。販賣第二級毒品之法定刑為「無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金」，刑度可謂重大。然同為販賣第二級毒品之

人，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同，或有大盤毒梟者，亦有中、小盤之分，甚或僅止於吸毒者友儕間為求互通有無之有償轉讓者亦有之，其販賣行為所造成危害社會之程度自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定本刑卻同為「無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金」，不可謂不重。於此情形，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合比例原則。經查，被告本案販賣甲基安非他命予他人之次數僅有1次，且其販賣對象只有1人，該次販賣之金額亦僅2,000元，數量亦微，較諸販毒集團尚屬零星小額，其販賣數量及販賣所得金額均非鉅額，且被告僅係單純販賣毒品，並無施用強暴、脅迫之不法手段，以其情節而論，其惡性尚不如專以販賣第二級毒品維生之販毒集團重大。其既非販賣第二級毒品之大盤或中盤商，則其販賣第二級毒品之行為尚未造成無可彌補之鉅大危害，衡其犯罪情狀在客觀上顯非不可憫恕，本院依其客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其犯罪情狀，就其本案販賣第二級毒品犯行，爰依刑法第59條之規定，予以酌量減輕其刑。

(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知甲基安非他命為政府管制之第二級毒品，具高度成癮性及濫用性，對於國民健康及家庭、社會健全危害甚鉅，猶無視政府向來嚴禁毒品流通之禁令，販賣甲基安非他命予他人以營利，致使毒害蔓延，本應予以重懲，且被告於偵查中否認犯行，迨至本院審理時方坦承犯行之犯後態度，兼衡被告之犯罪動機、目的、販賣毒品之次數、數量、獲利金額等犯罪情節及所生危害、前科素行，暨其自述之智識程度及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

(六)沒收：

1.扣案之行動電話1具（含門號0000000000號SIM卡1枚）為被告所有，供其聯繫本案交易毒品事宜所用等情，業據被告供

01 陳在卷（見本院訴字卷第263頁），該手機既係供被告為本
02 案犯行所用，自應依毒品危害防制條例第19條第1項規定宣
03 告沒收。

04 2.被告本案販賣毒品所得價金2,000元，為其本案犯罪所得，
05 雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，
06 並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執
07 行沒收時，追徵其價額。

08 3.另被告為警查獲時所扣得之安非他命1包、吸食器1組、分裝
09 袋1包等物，並無證據證明與本案有關，爰不於本案宣告沒
10 收。

11 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

12 本案經檢察官丁煥哲提起公訴，檢察官葉惠燕到庭執行職務。

13 中 華 民 國 114 年 11 月 12 日

14 刑事第四庭 審判長法官 李佳靜

15 法官 郭子彰

16 法官 余甯慈

17 上正本證明與原本無異。

18 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
19 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
20 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
21 逕送上級法院」。

22 書記官 李璵穎

23 中 華 民 國 114 年 11 月 13 日

24 附錄本案論罪科刑法條：

25 毒品危害防制條例第4條第2項

26 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒
27 刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。